

1500957-09.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500957-09.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500957-09.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2241714/2021 - DEL.POL.JARINU, 20055580 - DEL.POL.JARINU, 901/2021 -

DEL.POL.JARINU, 2241714 - DEL.POL.JARINU, 901/21/415 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATHAN DOS SANTOS FERNANDES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia em face de JONATHAN DOS SANTOS FERNANDES, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 18h45, na Estrada Municipal Atílio Squizzato, 4.810 (próximo ao "Bar do Caldo"), Jardim Roseiral, nesta cidade e comarca de Jarinu, o denunciado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 15 (quinze) microtubos contendo "crack", droga derivada da

cocaína, com massa líquida total de 3g, e 04 (quatro) eppendorfs de “cocaína em pó”, com massa líquida de 4,48g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o réu ofertou defesa prévia (fls. 116/119).

Os autos foram remetidos à E. Procuradoria Geral de Justiça, que chancelou a negativa de ANPP (fls. 143/153).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 154/155), prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram. Ministério Público se manifestou em memoriais orais.

A Defesa ofertou alegações finais escritas (fls. 174/181).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fl. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 16), do laudo preliminar de constatação da natureza tóxica (fls. 19/21), do laudo pericial químico de entorpecente (fls. 97/99), que atestou que as substâncias encontradas eram cocaína, de uso proscrito no Brasil. A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado JONATHAN DOS SANTOS FERNANDES.

Inquirida, a testemunha Cleiton Roberto de Souza, guarda municipal, disse que, em local conhecido pelo tráfico, notaram a presença do réu, apoiado em um carro; que, ao ver a viatura, o denunciado se evadiu; que, abordado, portava o acusado cocaína e crack; que, indagado, disse que era para seu uso e também para a venda; que venderia para o rapaz que estava no carro e que se evadiu; que não o conhecia anteriormente; que não conseguiu identificar quem era o motorista do carro.

A testemunha José Aílton Ferreira da Silva, também integrante da GCM, relatou que foram ao local para atender ocorrência de roubo de carga; que, no deslocamento, depararam-se com o réu próximo a um carro prata; que o réu tinha uma sacola na mão; que, ao avistar a viatura, o denunciado saiu em passos longos; que o abordaram; que constataram uma quantidade de drogas dentro da sacola; que o réu afirmou que a maior parte daquele entorpecente se destinava ao comércio, enquanto o restante era para consumo; que acredita ser maconha e cocaína ou cocaína e crack; que eram duas espécies de drogas; que já o conhecia antes dos fatos por morar nas proximidades; que o conhecia por ser usuário; que não tem nada contra ele; que o carro pertence a pessoa que sabe ser traficante e que atua no abastecimento; que o carro prata saiu em fuga; que reconheceu o carro bem como o motorista; que o ponto em que abordado o denunciado é conhecido pelo tráfico, por ser ermo; que já havia abordado o acusado anteriormente; que as quantidades que portava anteriormente eram diminutas.

Interrogado, o acusado JONATHAN DOS SANTOS FERNANDES disse que, no dia dos fatos, voltava do serviço a pé; que estava com a droga indo embora; que os policiais chegaram e o abordaram; que afirmou que a droga era sua para uso; que toda a droga se destinava ao consumo próprio; que usa crack, cheira “farinha” e fuma pedra; que trabalha sem registro; que paga 5 ou 10 reais pela droga; que nunca foi processado ou preso; que já passou por clínica de reabilitação; que não surtiu efeito.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado encontra-se em dissonância com o conjunto probatório, em especial com as testemunhas que efetuarão a diligência de apreensão das substâncias.

De proêmio, destaco que o réu foi preso em flagrante, o que, segundo asseverado por José Frederico Marques, consubstancia a “certeza visual do crime” (MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Brookseller, 1997, v. IV, p. 175).

No mais, não há por que se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris

tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional" (RT 752/589).

Por essa vereda caminha também o entendimento do Eg. TJ/SP:

Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova (TJSP; Apelação Criminal 0360928-92.2010.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2011; Data de Registro: 15/04/2011).

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia. Acrescento que a versão trazida pelo acusado restou ilhada dos elementos dos autos, especialmente à luz da quantidade de drogas apreendidas, da forma do acondicionamento e do local em que capturado - ponto conhecido pelo comércio espúrio -, ex vi do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas. Ademais, o relato fornecido sob o crivo do contraditório é divergente daquele ofertado em solo policial (fl. 09), o que fulmina a credibilidade de suas palavras. Observe, também, que, conquanto pudesse efetivamente estar sob o efeito de drogas, o fato de o acusado ser usuário não impede que ele estivesse no local também efetuando a venda de entorpecentes, como no caso, não se podendo desclassificar o delito, na esteira da jurisprudência:

"No mais, como é mais do que sabido, a eventual condição de usuário alegada pelo Réu em seus interrogatórios - não obsta o reconhecimento da atividade da traficância pelo mesmo agente, como bem já decidiu esta Câmara (Ap. nº 0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013): "Não se desconhece que os acusados possam ser usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício" (Apelação Criminal nº 0000731-32.2020.8.26.0022, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador ZORZI ROCHA, julgado em 07.03.2022).

In casu, os testemunhos dos guardas prestados em juízo, de forma coesa e harmônica, consubstanciam mesmo prova suficiente para um édito condenatório, sobretudo porque trouxeram aos autos um quadro deveras translúcido acerca do contexto delitivo e da participação efetiva do réu no crime em apreço.

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irreabilidade.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos

42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, em que pese a ausência de antecedentes (fl. 31), a lesividade das substâncias encontradas, especialmente o crack, impõe elevação na pena, razão pela qual fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

No entanto, para evitar bis in idem, deixo de valorar a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, já que o Pretório Excelso passou a considerar vedada a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014)

Desta feita, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Na falta de elementos acerca da capacidade financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no piso legal.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade e conduta social e personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 1 salário mínimo vigente, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR o réu JONATHAN DOS SANTOS FERNANDES, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor mínimo legal; substituída a primeira por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 1 salário mínimo vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.
Considerando que o réu responde o processo em liberdade, concedo-lhe o direito de apelar nesta condição, se por outro motivo não estiver preso.
Condene o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC.
Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:
Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;
Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;
Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada.
Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.
Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);
Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminhá-la para a Defensoria.
A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.
Publique-se. Intime-se.

Jarinu, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA